

1502947-57.2019.8.26.0625

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra a Ordem Tributária

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... dos acusados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA. A inexistência de elementos probatórios que demonstrem o vínculo associativo estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput e § 1º, e 34, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

1ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/n, Taubaté - SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502947-57.2019.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502947-57.2019.8.26.0625

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Ordem Tributária

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

A GONÇALVES DOS SANTOS TABACARIA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida contra ARY GONÇALVES DOS SANTOS, pela prática do crime do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90.

A denúncia narra que: a) o Réu era proprietário da empresa A. Gonçalves dos Santos - Tabacaria, Inscrição Estadual n. 688.240.718.116, CNPJ nº 06.017.426/0001-34; b) o acusado omitiu declarações de venda de mercadorias e, com isso, deixou de recolher ICMS no valor de R\$48.000,00; c) na oportunidade, foi lavrado ao AIM n. 4079859-8, em 24/10/2016; d) foi ajuizada uma ação anulatória de débito fiscal (processo n. 1014593-92.2017.8.26.0625), cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes; e) houve inscrição em dívida ativa em 31/10/2018 (CDA n. 1258100180) e ajuizamento de execução fiscal (15267553-58.2018.8.26.0625).

Em 13/02/2020, houve o recebimento da denúncia (fls. 96/98).

O Réu foi citado em 11/03/2020 (fls. 110) e apresentou resposta à acusação às fls. 111/120.

Às fls. 126/128, foi proferida decisão que: a) rejeitou a alegação de que a denúncia era genérica; b) determinou a requisição de cópia integral do AIIM 4079859-8; c) intimou a defesa técnica a esclarecer o objeto da perícia solicitada. A defesa se manifestou às fls. 138/139.

Às fls. 140/141, houve o indeferimento da prova pericial.

Às fls. 148/658, houve a juntada do processo administrativo.

Às fls. 663/665, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Em suas alegações finais, o MP defendeu que: a imputação foi confirmada pelas provas produzidas; há prova da autoria e da materialidade; o Réu deve ser condenado nos termos da denúncia; as questões ligadas à substituição tributária não interferem na apuração criminal; as teses suscitadas pelo Réu são isoladas; a pena deve ser fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

Em suas alegações finais, a defesa afirmou que: a denúncia é inepta; não há justa causa; há nulidade pelo indeferimento da prova pericial; não há que se falar em responsabilidade penal, uma vez que o Réu não estava obrigado a recolher o ICMS; não houve sonegação fiscal; houve o empréstimo mencionado; não há prova do dolo específico; o Réu deve ser absolvido.

É o relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Da inépcia da denúncia

O art. 41 do CPP elenca os requisitos que devem constar numa denúncia:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Com relação à narrativa dos fatos, o entendimento é de que a denúncia é regular quando a imputação é feita de forma clara, com exposição das condutas imputadas ao Réu e suas circunstâncias:

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. A exordial acusatória preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação processual penal em vigor (CPP, art. 41), porquanto qualificou os acusados e descreveu, de forma clara e pormenorizada, a infração penal a eles imputada, com todas as suas circunstâncias e elementares, apresentou rol de testemunhas e foi instruída com suporte probatório mínimo.

Preliminar afastada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO.

INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Prisão em flagrante da acusada Luciana, que trazia consigo 194,8g de maconha, ocultados em sua cavidade vaginal, em procedimento de revista prévio ao ingresso no estabelecimento prisional em que recluso o acusado Wesley, seu companheiro e destinatário da droga. Depoimentos das agentes de segurança penitenciária, prestados sob o crivo do contraditório, que se mostraram seguros, coerentes e harmônicos, em consonância com os demais elementos de prova. Acusada Luciana que confessou a imputação, embora tenha afirmado que agiu sob ameaça de Wesley. Este acusado, de seu turno, afirmou que coagiu Luciana a praticar tal conduta. Versões que, embora contenham as elementares do tipo, não encontram respaldo no conjunto probatório, ao menos no que tange à delimitação das responsabilidades dos acusados. Não comprovada a relação lógica entre episódio pretérito de violência doméstica, que remete a 2014, e suposta coação moral irresistível com vistas à prática do ato em questão. Luciana mantinha relacionamento amoroso com Wesley e o visitava regularmente, desde que fora preso, em 2015. Testemunhas que não foram precisas quanto às supostas ameaças. Incumbe à defesa a prova da ocorrência da alegada coação moral irresistível, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 156 do C.P.P.). Em se tratando o tráfico de drogas de crime unissubsistente e permanente, não há que se falar em reconhecimento de meros atos preparatórios ou tentativa em relação a Wesley, que efetivamente concorreu para o crime em questão, em sua forma consumada. Não configuração de crime impossível. A mera existência de agentes penitenciários, vigilância, revista e outras formas de fiscalização em estabelecimento prisional não caracteriza ineficácia absoluta do meio empreendido para fazer ingressar drogas no local, já que aqueles recursos, embora eficientes, não são capazes de impedir toda e qualquer ação delitiva. Mantida a condenação dos acusados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. INEXISTÊNCIA.

ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA. A inexistência de elementos probatórios que demonstrem o vínculo associativo estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/06, conduz à absolvição dos acusados quanto ao crime de associação para o tráfico, por insuficiência probatória. PENAS. Ré Luciana. Base no mínimo legal, assim mantida ao final da segunda etapa. Apesar de Luciana ter confessado os elementos típicos do tráfico ilícito de entorpecentes, alegou uma causa de exclusão da culpabilidade, razão pela qual inviável o reconhecimento da atenuante. Negativa do redutor pelas circunstâncias do crime, considerada a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (194,8g de maconha), que os acusados pretendiam introduzir em estabelecimento prisional, circunstâncias a indicar que não se trata a apelante de "traficante de primeira viagem", figura visada pela excepcional causa de diminuição de pena Mantido o acréscimo de 1/6 pela causa especial de aumento do art. 40, III, da Lei Antidrogas. Penas mantidas. Réu Wesley. Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, pela má antecedência e personalidade malformada. Afastamento da segunda circunstância, por ausência de elementos nos autos, com aumento das penas em 1/12. Na segunda etapa, reconhecimento, nesta Instância, da atenuante da confissão espontânea, compensada com a agravante da reincidência. Não era mesmo o caso de reconhecimento do privilégio, diante da reincidência e dos maus antecedentes do acusado. Mantido o acréscimo de 1/6 pela causa especial de aumento do art. 40, III, da Lei Antidrogas. Penas reduzidas. REGIME. Manutenção do regime inicial fechado. Quantum de penas superiores a quatro anos, gravidade concreta do delito diante da natureza e quantidade e de drogas, bem como das circunstâncias do crime em concreto, com vistas à prevenção delitiva e tutela social, ao menos no início do cumprimento da pena, a par da reincidência e maus antecedentes de Wesley. BENEFÍCIOS. Incabíveis a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o sursis penal, tendo em conta a pena concretizada, além da insuficiência da repressão delitiva caso concedida qualquer dessas benesses, ao que se somam a reincidência e os maus antecedentes de Wesley. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Por força do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais, sendo a fase executória o momento propício para aferir eventual hipossuficiência econômica do sentenciado, para fins de satisfação da pena. Precedente. Pedido de isenção das custas processuais indeferido nesta fase cognitiva da persecução penal Recursos defensivos parcialmente providos para absolver Luciana e Wesley do crime de associação para o tráfico, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como redimensionar as penas de Wesley, quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, para 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão e 631 dias-multa mínimos, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(TJSP; Apelação Criminal 0000201-94.2017.8.26.0616; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/06/2021; Data de Registro: 15/06/2021) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - Preliminar - Nulidade por inépcia da denúncia - Inocorrência - Peça acusatória que identifica e qualifica o acusado, bem como descreve com clareza as imputações, possibilitando o exercício pleno da ampla defesa - Observância do art. 41 do CPP - Mérito - Pleito de absolvição - Impossibilidade - Materialidade e autoria sobejamente demonstradas - Crime que nem sempre deixa vestígios - Prova oral que dá a certeza do cometimento do delito pelo acusado - Desclassificação para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor - Descabimento -- 'Animus' do agente bem evidenciado. Ademais, os atos não se deram em ambiente público ou acessível ao público - Desistência voluntária - Inviabilidade - Crime que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente - Instituto incompatível com a tentativa reconhecida - Condenação mantida - Pena - Fração de redução pela tentativa já aplicada no máximo legal - Regime fechado único adequado à espécie, ante a gravidade concreta dos fatos - Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Criminal 1500611-19.2020.8.26.0537; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/01/2022; Data de Registro: 27/01/2022) (grifos acrescidos)

No caso concreto, não se pode falar na inépcia da denúncia, uma vez que os fatos imputados são narrados com clareza, com indicação da conduta atribuída ao Réu (na condição de "proprietário" da A. Gonçalves dos Santos - Tabacaria, o acusado teria omitido vendas de mercadorias, deixando de recolher tributos, o que foi objeto de autuação (AIIM n. 4.079.859-8) e posterior inscrição em dívida ativa (CDA n. 1258100180)).

Assim, há uma imputação específica, sobretudo quando se tem ciência de que o Réu tem conhecimento de toda a atuação administrativa (tanto que a impugnou judicialmente).

Desta forma, rejeito a tese defensiva.

Da justa causa

A tese também não pode ser acolhida, já que a representação de fls. 5 não é o único elemento no qual se baseou a denúncia nem o único elemento probatório colhido ao longo do processo.

Como exemplo, nota-se que, ainda na fase investigatória, houve oitivas (fl. 24) e juntada de outros documentos ligados à autuação, como se vê às fls. 44/48, 65/71 e 75/77.

Além disso, durante o processo, foi anexada a íntegra do procedimento administrativo.

Por isso, rejeito a tese defensiva.

Da prova pericial

O STF tem precedente no sentido de que, quando as provas já anexadas forem suficientes para a comprovação da conduta tipificada no art. 1º da Lei n. 8.137/1990, é desnecessária a realização de perícia contábil:

EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. DENÚNCIA: ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. LEI PENAL NO TEMPO. LEI NOVA MAIS SEVERA. PERÍCIA CONTÁBIL. CP, ART. 71. LEI Nº 4.729/65. LEI Nº 8.137/90. I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP. II. - Se vários delitos em continuação foram cometidos na vigência da Lei nº 4.729/65, mais branda, e um cometido quando vigente a Lei nº 8.137/90, mais severa, aplica-se esta última. Precedente do STF: Extradição nº 714-Rep. Italiana. III. - A falta de perícia contábil no crime de sonegação fiscal não impede o curso da ação penal, se os demonstrativos fiscais e os demais elementos existentes nos autos são suficientes para comprovar a materialidade do delito e a sua autoria. IV. - HC indeferido. (HC 76382, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 29-08-2003 PP-00034 EMENT VOL-02121-14 PP-02810) (grifos acrescidos)

O TJSP também já se manifestou nesse sentido:

APELAÇÃO. Crime contra a ordem tributária. Artigo 1º, inciso II, da Lei n. 8.137/90. Recurso defensivo. Preliminar de prescrição. Não cabimento. Delito que somente se consuma com o lançamento definitivo do crédito tributário, o que se consubstancia com a emissão da certidão de dívida ativa. Pleito de absolvição por ausência de comprovação da materialidade. Prescindibilidade de perícia técnica. Supressão e redução de tributos comprovada por meio da palavra do agente fiscal, pelo processo administrativo tributário, pela certidão de dívida ativa, bem como pela confissão da acusada. Dosimetria da pena. Viável a redução da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva. Regime aberto devidamente fixado na r. sentença. Cabível a redução do montante fixado a título de sanção pecuniária em razão da condição econômica da apelante. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 0079120-59.2011.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 06/07/2017)

(grifos acrescidos)

No caso concreto, os seguintes elementos indicam ser desnecessária a prova pericial: autuação de fls. 148/154, cópia do livro diário de fl. 392 (na qual é lançado o suposto empréstimo), a notificação de fl. 469/470, o extrato do IR de fls. 471/479 e o contrato de fls. 481/482.

Por isso, reitero os termos da decisão de fls. 140/141 e rejeito a tese da nulidade.

Da materialidade e da autoria

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito.

Os crimes previstos no art. 1º da Lei n. 8.137/1990 pressupõem, inicialmente, a supressão ou redução de tributo, contribuição social ou qualquer acessório.

Por isso, entende-se que o crime é material, exigindo um resultado naturalístico (supressão ou redução do tributo, contribuição social ou qualquer acessório), de sorte que é necessário haver o lançamento do tributo:

Súmula vinculante 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.

O art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 tipifica a conduta de suprimir ou reduzir tributo, contribuição social ou acessório por meio de omissão de informação ou apresentação de declaração falsa às autoridades fazendárias.

Sobre os elementos do tipo penal do art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, confira-se a doutrina:

“A conduta fraudulenta consiste em omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Objeto do crime é a declaração omitida ou feita à autoridade fazendária, seja ela feita em papel, ou, como é mais comum atualmente, por meio eletrônico.

Omitir informação é não declarar, constituindo-se em crime omissivo. Como exemplo, pode ser citado o caso do contribuinte que, embora tenha renda tributável, não entrega a declaração de rendimentos, suprimindo o imposto de renda, mediante omissão de informação (...). Cuida-se de fraude caracterizada pelo silêncio contraposto à exigência legal de declarar a ocorrência do fato gerador.

(...)

Autoridade fazendária será aquela competente para receber e processar as declarações prestadas pelos contribuintes” (BALTAZAR Junior, José Paulo. Crimes federais. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 815) (grifos acrescidos)

No caso concreto, a materialidade delitiva fica comprovada pelo auto de infração, com efetiva indicação da supressão/redução de tributo (148/154), pelo fim do procedimento administrativo (fls. 631/635), pela inscrição em dívida ativa (fls. 648/656), pela representação para fins penais (fls. 658), pelos documentos de fls. 471/479, 481/482 e 392, apresentados à autoridade fazendária, e pelas provas orais produzidas.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado ARY GONÇALVES DOS SANTOS foi o autor do crime do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, conforme será devidamente demonstrado a seguir.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha DENISE VANNI DOS SANTOS CUNHA DE DEUS afirmou que: o Réu é cliente do escritório dela de contabilidade; lembra da fiscalização; a empresa do Réu recebeu uma notificação para entrega de documentos (notas, boletos etc.); os documentos foram entregues ao fiscal; o fiscal autuou com base em um empréstimo que foi feito em dezembro/2012; o empréstimo foi pago durante o ano de 2013, até junho; o fiscal não “aceitou” tal pagamento; o fiscal não deu nenhuma informação; ficaram sabendo do resultado só com a lavratura do auto de infração; dentro mesmo ano de 2012, foi feito um empréstimo de R\$118.000,00, dentro do próprio ano (esse foi aceito); o outro é que não foi aceito; na notificação feita

pelo fiscal, falava em outros empréstimos (inclusive bancários); o de R\$192.000,00 não foi aceito pelo fiscal; não enxerga diferença entre os empréstimos; o empréstimo de R\$118.000,00 foi feito e pago no mesmo ano; o de R\$192.000,00 foi feito em 2012 e foi pago em meses de 2013; o fiscal queria falar diretamente com o Réu, que não quis recebê-lo; é contadora há uns 30 anos; às vezes, os fiscais querem falar diretamente com o proprietário, não com o contador; entende que não houve omissão por parte do Réu; o contrato de mútuo foi entregue ao fiscal; esse valor foi pego através de várias pessoas, por isso não tinha a documentação comprobatória; a Souza Cruz sugere a compra em maior volume antes do aumento de preço; o aporte foi para isso; não tem comprovante dessas operações "menores". Em seu interrogatório, o Réu ARY GONÇALVES DOS SANTOS afirmou que: todo produto que negocia na tabacaria tem o seu ICMS pago na origem; não pagava ICMS; os R\$192.000,00 foram recebidos de várias pessoas como empréstimo; todos os valores foram recebido em dinheiro vivo; fez um depósito no banco para pagamento de duplicatas; foi justificado como pagamento de mútuo; não tem comprovante do retorno dos valores para as pessoas que emprestaram; não se recorda se chegou a pagar alguma duplicata com esses valores;

No caso concreto, as provas produzidas convergiram para o seguinte cenário: a) o Réu era "proprietário" da A. Gonçalves dos Santos - Tabacaria; b) a referida sociedade, através do Réu, omitiu operações tributáveis pelo ICMS, o que ensejou o não pagamento de R\$53.444,99 (fl. 149); c) para "regularizar" sua contabilidade, o Réu simulou um empréstimo seu em favor da sociedade, no valor de R\$192.000,00 (fl. 392).

Os seguintes elementos indicam que o empréstimo em questão não existiu e foi uma via para camuflar a omissão de operações tributáveis: a) mesmo sendo um valor considerável (R\$192.000,00), o Réu não incluiu esse empréstimo na sua declaração de imposto de renda (fls. 471/479); b) não há comprovação bancária dessa transação, mesmo de elevado valor; c) o Réu alega que tomou esse valor junto a várias pessoas, mas não tem comprovante nem da contratação nem da devolução, não obstante o valor elevado da suposta transação.

É preciso destacar que a questão sobre eventual substituição tributária está superada pelas decisões cíveis e pelo fato de que a própria autoridade fazendária reconheceu que tal ardil ensejou a redução do pagamento do tributo (tanto que autuou a sociedade).

Ressalte-se que o STJ entende que basta a presença do dolo genérico (verificada no caso concreto), não se exigindo o dolo específico:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDIBILIDADE. RESP NÃO ADMISSÍVEL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na caracterização dos crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico. Precedente.

2. O acórdão impugnado asseverou que a acusada tinha plena ciência da obrigatoriedade do recolhimento do imposto (ISS) a partir do dia 8/8/2008, decorrente da decisão proferida na ADI n. 3.089/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

3. A discussão sobre a alegada violação à coisa julgada material relativa à invocada isenção deve ser examinada pela jurisdição especializada em direito tributário, e não na justiça criminal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1933842/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) (grifos acrescidos)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INC. II, DA LEI N. 8.137/90. DOLO. COMPENSAÇÃO. DISCUSSÃO NO CÍVEL. TRANCAMENTO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO-CABIMENTO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Os delitos tipificados no art. 1º da Lei n. 8.137/90 são materiais, dependendo, para a sua consumação, da efetiva ocorrência do resultado, não necessitando, porém, para sua caracterização, da presença do dolo específico.

3. Orienta-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que a pendência de discussão acerca da extinção do crédito tributário, perante o Judiciário, ainda que por compensação, não impossibilita a instauração da ação penal cabível, dada a independência das esferas cível e criminal.

4. O mero ajuizamento de ação de compensação não é causa de extinção da punibilidade, trancamento ou suspensão da ação penal.

5. Nos termos do que dispõe o art. 93 do CPP, a suspensão do curso da ação penal constitui faculdade do magistrado, para aqueles casos em que a solução depende do deslinde no cível para a sua conclusão.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 43.724/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014) (grifos acrescidos)

Tais elementos suprem os pressupostos para a tipificação da conduta à previsão do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, uma vez que efetivamente houve omissão de informações sobre operações tributáveis à autoridade fazendária, o que implicou a redução do pagamento de tributo (ICMS).

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o réu ARY GONÇALVES DOS SANTOS, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que o réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu ARY GONÇALVES DOS SANTOS pela prática do crime tipificado no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990.

Da dosimetria da pena

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar negativamente esta circunstância judicial; b) Antecedentes: trata-se de acusado sem antecedentes criminais (conforme entendimento da súmula 444 do STJ), motivo pelo qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não

há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: tal circunstância também deverá ser valorada como neutra.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, não há agravantes a reconhecer.

Não há atenuantes a reconhecer.

Assim, fixo a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

No caso concreto, tendo em vista que a sonegação não alcançou valores exorbitantes, não é possível aplicar a causa de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1.990.

Também não há causas de diminuição a reconhecer.

Por isso, a pena definitiva é fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Considerando a extinção do BTN (previsto no art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 8.137/1990), aplico a sistemática do CP e fixo o dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena.

Considerando, entretanto, que o Réu preenche os requisitos do art. 44, I a III, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a prestação de serviços à comunidade, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do CP), e a prestação pecuniária de 08 (oito) salários mínimos vigentes à época do fato, a serem pagos a entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, § 1º, do CP).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu ARY GONÇALVES DOS SANTOS pela prática do delito previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, às penas de 2 anos de reclusão, ser cumprida em regime inicial ABERTO e ao pagamento de 10 dias-multa no valor individual de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando, entretanto, que o réu preenche os requisitos do art. 44, I a III, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do CP, e a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA de 08 (oito) salários mínimos vigentes à época do fato, a serem pagos a entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, § 1º, do CP).

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO os sentenciados ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804).

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, DEIXO DE DECRETAR a prisão preventiva dos réus por entender ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante do regime inicial de cumprimento e da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva.

Após o trânsito em julgado, nos termos dos artigos 123 do Código de Processo Penal e 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, os objetos

apreendidos ficarão disponíveis para os interessados, desde que comprovada a propriedade, pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, fica determinado seu perdimento, para posterior alienação em leilão ou destruição, se o caso.

COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Taubaté, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA